

1501550-34.2021.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico. Senão vejamos. Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, a materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de constatação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501550-34.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2279673/2021 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 20806166 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3140/21/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2279673 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 3140/21/301 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

ISAC DE SOUZA JESUS

Data da Audiência:

25/07/2022

A S S E N T A D A

Aos 25 de julho de 2022, às 13 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini – Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, ISAC DE SOUZA JESUS (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Evandro Reche Nogueira, Alberto Luiz Peneque e Yuri Ivaristo Andrade Rosa; ausentes as testemunhas Ingryd Elenir andrade Rosa e Willian Pinheiro da Rocha.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Evandro Reche

Nogueira, Alberto Luiz Peneque, Ingryd Elenir Andrade Rosa e Yuri Ivaristo Andrade Rosa, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra às partes, por elas foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas Ingrudy Elenir Andrade Rosa e Willian Pinheiro da Rocha. Na sequência, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Homologo a desistência das partes quanto a oitiva das testemunhas Ingrudy Elenir Andrade Rosa e Willian Pinheiro da Rocha. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, absolvendo-se réu dos termos do artigo 35 da Lei 11.343/2006, persistindo, no mais, os exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. ISAC DE SOUZA JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos com a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, em data incerta, porém, anteriormente ao dia 13 de outubro de 2021, e até esta data, o acusado associou-se com o adolescente G. de O. G. para o fim de praticarem reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Consta, ainda, que no dia 13 de outubro de 2021, às 23h16min, na Rua Roque Rodrigues de Souza, nº 220 – Morro do Algodão, Praia das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, ISAC DE SOUZA JESUS, com unidade de propósitos e identidade de desígnios com o adolescente G. de O. G., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e guardava 03 (três) porções de Cocaína, com peso total de 5,96g; 01 (uma) porção de Maconha, com peso total de 6,39g; 35 (trinta e cinco) porções de Maconha, com peso total de 265g; e 02 (duas) porções de Maconha, com peso total de 7,83g. A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2021 (fls. 97/98). O réu foi citado (fls. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/113). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum, bem como foram realizados os interrogatórios dos réus, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Encerrada a instrução criminal, na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A ação é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico. Senão vejamos. Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, a materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/12), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), auto de constatação preliminar (fls. 25/26), laudos periciais (fls. 176/179, 180/184 e 185/187), que confirmam a natureza das substâncias apreendidas e demais provas produzidas nos autos. A autoria delitiva, também, restou demonstrada e caracterizada nos autos. A testemunha e policial militar EVANDRO RECHE NOGUEIRA informou, na delegacia, que efetuavam regular patrulhamento pelo bairro Morro do Algodão, ao adentrarmos a referida via, avistaram 03 indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram se evadir e se misturaram a mais 03 pessoas que ali estavam, pessoas essas arroladas como testemunha neste RDO, após efetuada a abordagem identificaram o senhor Isac de Souza de Jesus, RG 54314044, que em ato contínuo chegou a adentrar o quintal da casa nº 220 na rua local dos fatos, acompanhado do senhor Gabriel de Oliveira Gomes, RG 57.211.791, sendo que o senhor Isac dispensou 1 porção de maconha, 3 porções de cocaína embaladas a vácuo e R\$ 100,00 (Cem Reais) em espécie. Que durante a busca pessoal aos demais, foi localizada com o senhor Gabriel de Oliveira Gomes, RG 57.211.791 a quantia de 32 reais. Que, com o senhor David Cardoso da Silva, foram localizadas 02 porções de maconha e 01 celular Samsung s8. Com as testemunhas nada de ilícito foi encontrado. Que, durante a busca no quintal da

residência nº 220, foi localizada uma sacola plástica contendo 35 porções de maconha, diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito, e as partes conduzidas para esta unidade policial, onde a autoridade policial tomou as medidas cabíveis para os fatos. Quanto aos 3 indivíduos que estavam na rua no momento dos fatos, identificaram o senhor Yuri Ivaristo Andrade Rosa, RG 60.367.998, as senhora Ingrid Elenir Andrade Rosa, RG 56.840.960, e o senhor Willian Pinheiro da Rocha, RG 39.962.302, onde nada de ilícito fora encontrado com os mesmos. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial militar ALBERTO LUIZ PANEQUE que também participou dos fatos narrados da denúncia na delegacia, prestou depoimento em Juízo, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega. A testemunha INGRYD ELENIR ANDRADE ROSA, na delegacia, declarou que é moradora da casa onde a PM arrecadou drogas ilícitas durante uma operação. Que, segundo relatos dos PMS, um dos abordados, GABRIEL, seu namorado, ao ser perseguido pelos PMS, acabou por adentrar no quintal de sua casa e "dispensou" um saco plástico contendo drogas ilícitas a fim de fugir do "flagrante". Que neste momento se encontrava próxima de sua residência voltando da casa de sua sogra. Que a pessoa de GABRIEL é seu namorado. Que não sabia que GABRIEL traficava drogas. Que GABRIEL mora bem próximo à casa da declarante. A testemunha YURI IVARISTO ANDRADE ROSA, na delegacia, disse que é morador da casa onde a PM arrecadou drogas ilícitas durante uma operação. Que um dos abordados, ao ser perseguido pelos PMS, acabou por adentrar no quintal de sua casa e, segundo relatado pelos próprios PMS, a pessoa de GABRIEL "dispensou" um saco plástico contendo drogas ilícitas a fim de fugir do "flagrante". Que neste momento se encontrava no portão de sua residência. Que a pessoa de GABRIEL é namorado de sua irmã INGRID. Que não sabia que GABRIEL traficava drogas. Que GABRIEL mora bem próximo a casa do depoente. Que, quando adolescente, foi apreendido por tráfico de drogas, no entanto, de lá para cá, entrou para a igreja e nunca mais se envolveu em nada ilícito. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha WILLIAN PINHEIRO DA ROCHA disse que mora próximo do local de abordagem da PM. Que na operação policial houve correria, mas não sabe dizer quem estava com drogas. Que estava no portão da casa de YURI conversando com este. Que YURI está congregando em uma igreja próxima e conversavam sobre o tema quando ocorreu a operação policial. Que a pessoa de GABRIEL é namorado da irmã de seu amigo YURI. Que não sabia que GABRIEL traficava drogas. Que GABRIEL mora bem próximo a casa do depoente. Em seu interrogatório policial o réu ISAC DE SOUZA JESUS disse que realmente exerce a função de "vapor" (vendedor de drogas ilícitas) no local onde se deu a operação da PM e trabalha para a pessoa de GABRIEL, que também foi abordado pelos PMS. Que a cada pacote com doze porções de maconha, dez repassa o dinheiro para GABRIEL e duas é lucro do interrogado. Que o adolescente DAVID é usuário e não "trabalha na biqueira". Em Juízo, negou a prática do crime. Disse que foi até o local para pagar uma dívida com o Gabriel e também para comprar mais drogas. Como se vê, a versão do réu em Juízo está isolada das demais provas constantes nos autos. De outro lado, a versão dos policiais militares, a confissão extrajudicial e demais testemunhas ouvidas em Juízo, bem como os entorpecentes apreendidos formam um conjunto probatório coeso e suficiente para comprovar a autoria delitiva. Afasto a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio do acusado. Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em solo policial quanto em juízo, infere-se que estes adentraram à residência pautados por fundadas razões que levavam a presumir a configuração de flagrante delito de tráfico de entorpecentes. Isto porque, ao avistar a viatura o acusado dispensou uma sacola e correu para dentro do imóvel. Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos

demais casos - flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido". (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, o acusado estava em posse de grande quantidade de entorpecentes no interior da residência vistoriada. Rechaço, igualmente, a alegação de nulidade da busca pessoal realizada. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista pessoal do acusado, com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, ocorreu de modo regular, com espreque em fundada suspeita de prática delituosa, inexistindo, a

despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa. No caso sub judice, conforme já delineado, vê-se presente a justa causa de forma inequívoca, autorizando a realização da revista pessoal diante da inquestionável conduta suspeita do acusado. Nesse sentido: “TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. (...)”. (STJ Habeas Corpus nº 552.395-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 20.02.2020). No mais, como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico. Isto porque, as declarações dos policiais militares foram coesas desde a fase inquisitiva. Além disso, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a dinâmica da abordagem, o comportamento do acusado logo antes da apreensão, bem como o local, conhecido como ponto de tráfico, demonstram a autoria delitiva. Ademais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim “(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Cediço, ainda, que não há impedimento de que o usuário seja também traficante. Ainda que ficasse provada, a condição de usuário não exclui, necessariamente, a prática do crime de tráfico de drogas. Pelo contrário, a experiência mostra que é comum a traficância entre dependentes e usuários justamente para viabilizar o sustento do consumo próprio, sendo inviável o afastamento do dolo ou desclassificação do delito para outro de menor gravidade (TJSP. Apelação Criminal nº 1.167.864.3. Rel. Juvenal Duarte. Quinta Câmara Criminal, J. 15.05.08). Consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, litteris: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudica-lo, o depoimento deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte”. (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). 0

conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que o réu trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018). E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021;

Data de Registro: 10/02/2021). Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre o réu e o adolescente. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe. A causa especial de aumento de pena do crime de tráfico envolvendo adolescente, conforme previsão do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 também restou devidamente configurada. Assim, tendo em vista a prova produzida e os argumentos apresentados, é de rigor a parcial procedência da ação nos termos acima delineados. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal c.c. artigo 42 da Lei 11.343/06, não há circunstâncias que ensejem elevação da pena-base, razão pela qual fixo a reprimenda no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, não obstante, considerando que a pena já está no mínimo, inviável reduzi-la nesta etapa, em observância ao que determina a súmula 231 do C. STJ. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso, VI da Lei nº 11.343/06, logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. Tendo em vista que o réu trazia consigo relevante quantidade de entorpecentes e que já sofreu condenação por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Por isso, fixo a pena para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do acusado, fixo a valor de cada dia multa no mínimo legal. Observando-se o disposto na súmula 719 do STF, para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, anoto que, inobstante a primariedade do acusado, conheço que o regime prisional adequado para início de cumprimento da censura penal deva ser o regime mais severo – fechado. Isto porque, o acusado recrutou um adolescente para participar da conduta criminosa. Assim, vislumbra-se que a culpabilidade extrapola aquela elementar à espécie, ressaíndo do ordinário. Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2º, CPP, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu ISAC DE SOUZA JESUS, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial FECHADO, além de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06. Ainda, ABSOLVO o réu da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP. DECRETO O PERDIMENTO do valor e dos objetos apreendidos em favor da União. O réu poderá recorrer em liberdade. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), expeça-se certidão de sentença do valor remanescente, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas – Funad. VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r.

sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EiQfuVW7xcZAgW0k459fbnkBY8VbflX3u0yP0SVqlA4lVQ?e=DUY151